

1018398-90.2022.8.26.0071

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Prestação de Serviços

Magistrado: JOAO AUGUSTO GARCIA

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 17/12/2022

... DA SILVA RETTO JUNIOR, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA em face de BANCO DO BRASIL S/A, também qualificado nos autos, alegando que foi vítima de uma fraude, na qual foram utilizados dados sigilosos relativos à sua conta corrente e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

5ª Vara Cível

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

1018398-90.2022.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1018398-90.2022.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços

Requerente:

Adalberto da Silva Retto Jr

Requerido:

Banco do Brasil S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOAO AUGUSTO GARCIA

VISTOS.

ADALBERTO DA SILVA RETTO JUNIOR, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA em face de BANCO DO BRASIL S/A, também qualificado nos autos, alegando que foi vítima de uma fraude, na qual foram utilizados dados sigilosos relativos à sua conta corrente e movimentação financeira, que deveriam ser guardados pelo Requerido, causando-lhe danos materiais no valor aproximado de R\$ 30.000,00.

Impetrou com a presente ação a fim de requerer tutela antecipada para que seja determinado ao Réu abster-se de efetuar qualquer tipo de desconto nos vencimentos do Autor, até que se confirme por sentença a presente Liminar, bem como o não registro de seu nome em cadastro de inadimplentes, a apresentação das gravações do hall de entrada da agência e do terminal do caixa eletrônico da Av. Getúlio Vargas, na data de 04/07/2022, no horário entre as 15:30 e 17:00hs, para a comprovação dos fatos sob pena de multa diária. Ainda, a condenação do Requerido ao pagamento de danos materiais no valor aproximado de R\$ 30.000,00 e a danos morais em R\$ 20.000,00. E, igualmente, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Acostou documentos de fls. 46/72.

Indeferida a tutela de urgência, fls. 82/89.

Citado, o Requerido apresentou contestação de fls. 129/160. Preliminarmente, alegou a falta de interesse processual do autor e a ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que inexistia ato ilícito por parte do Requerido, bem como não foram apresentadas provas concretas do alegado. Ademais, eventual fraude é decorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, portanto, presentes as excludentes de responsabilidade em relação à instituição financeira. Da mesma forma, os fatos não dão causa a possível reparação por dano moral. Assim, pleiteou a extinção do processo sem julgamento do mérito ante as preliminares arguidas, ou, na hipótese de análise do mérito, a total improcedência da ação.

Instados a apresentarem novas provas, a parte autora requereu a apresentação de prova documental, e a parte ré declinou do direito à dilação probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, posto que a matéria em discussão é exclusivamente de direito, amparada no contrato firmado entre as partes, não exigindo a produção de qualquer outro meio de prova para resolver a pendência.

Nesse sentido:

"Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (TFR-5ª Turma, Ag. 51. 774-MG, rei. Min. Geraldo Sobral, j.27.02.89, negaram provimento ao agravo, v.u. , DJU 15.5.89, p.7.935).

"O Juiz somente está obrigado a abrir a fase instrutória se, para o seu convencimento, permaneceram os fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, passíveis de prova testemunhal ou pericial" (JUTACSP - Lex 14 0/285, Rei. Boris Kauffman).

"O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias"(STJ.- 3ª Turma:, Resp 251.038/SP, J. 18.02.2003, Rel. Min. Castro).

Contém o artigo 4º do Novo Código de Processo Civil princípio a ser aplicado no ordenamento processual civil que as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral de mérito, incluída a atividade satisfativa.

Certamente que tal princípio não pode ferir a garantia do amplo direito de defesa, porém não é o caso dos autos.

Afasto a preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir, pois eventual responsabilidade do banco é questão que adentra ao mérito da demanda e com ele será apreciado.

No mesmo sentido em relação à preliminar de ilegitimidade passiva.

Trata-se de ação declaratória. A parte autora pleiteia a declaração de inexigibilidade de transações bancárias, bem como indenização por danos morais.

Pela narrativa do próprio autor, parte da qual ora se transcreve... "recebeu uma ligação onde se identificaram como sendo da agência 6533 do Banco do Brasil, essa agência é onde mantém sua conta corrente... na ligação informaram se tratar de assunto de MÁXIMA URGÊNCIA onde sua conta corrente estaria sendo clonada, objeto de

fraude, sendo necessário seu comparecimento a agência mais próxima do Banco do Brasil para procedimentos no sentido de bloquear as operações em tramite... conforme orientação do "Agente" recebeu em seu celular com o logo do Banco do Brasil um código de segurança para aplicar no Caixa Eletrônico para efetuar o Bloqueio da operação fraudulenta... ao chegar a agência mais próxima de seu local de trabalho (Ag. Getúlio Vargas), e se posicionar diante do Caixa Eletrônico dentro da agência do Banco Réu, seguindo as orientações do "Agente", o Requerente de fato recebeu o CODIGO para acessar o serviço de ajuda... Após efetuados os comandos o Requerente recebeu um Protocolo sob o nº20220409350789 e deu prosseguimento ao feito".

Considerando-se como verídicos os fatos narrados pelo autor, por aí se vê, que, infelizmente, repassou dados sigilosos para terceiros que, com uso de dados pessoais e intransferíveis, realizou, desta forma, a fraude.

Ora, o próprio autor realizou a operação através de seu aparelho celular e efetuou a confirmação pelo caixa eletrônico.

Tal modalidade de golpe praticado por fraudadores é demasiado conhecida. É sabido que as instituições financeiras não ligam para os clientes informando eventual clonagem de sua conta e não solicitam procedimentos via celular e caixa eletrônico. Ademais, o autor é professor universitário de renomada universidade pública, não podendo ser considerado uma pessoa de pouco conhecimento a respeito de tal situação peculiar.

É certo que, conforme acentua o requerido, as transações bancárias ocorrem em ambiente seguro da instituição de relacionamento do usuário que seja acessado por meio de uma senha ou de outros dispositivos de segurança integrados ao telefone celular, como reconhecimento biométrico e reconhecimento facial ou uso de token.

Não se pode atribuir culpa da instituição financeira no presente caso.

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura, mas facultat-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpado, pois sua culpa é presumida.

Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano.

O mesmo art. 14 do CDC também disciplina, em seu § 3º:

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

- I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
- II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A hipótese prevista no inciso II, do parágrafo 3º, do artigo 14 do CDC aplica-se no caso em concreto posto na lide.

Não se desconhece que o fornecedor de serviços que oferece atrativos e comodidades para atrair consumidores, tais como cartões magnéticos e caixas rápidos, tem ciência dos riscos decorrentes da sua atividade, dentre eles, a real possibilidade de que pessoas inescrupulosas apliquem golpes em seus clientes.

Todavia, é do correntista o dever de guarda de seu cartão e do sigilo de sua senha pessoal, não respondendo a instituição financeira por eventual contratação de

empréstimo e realização de saques no terminal de autoatendimento, efetuados por terceiros mediante utilização do cartão bancário e senha pessoal do correntista, cuja guarda é de sua exclusiva responsabilidade.

Observe-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - EMPRÉSTIMOS E SAQUES EM CAIXA ELETRÔNICO - CONTESTAÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - DEVER DO CORRENTISTA DE GUARDA DO CARTÃO BANCÁRIO E SIGILO DA SENHA - FURTO NÃO COMUNICADO AO BANCO - AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos negócios jurídicos firmados com as instituições financeiras. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva da vítima. Inteligência do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC. É do correntista o dever de guarda de seu cartão e do sigilo de sua senha pessoal, não respondendo a instituição financeira por eventual contratação de empréstimo e realização de saques no terminal de autoatendimento, efetuados por terceiros mediante utilização do cartão bancário e senha pessoal do correntista, cuja guarda é de sua exclusiva responsabilidade. Em se tratando de furto, se junto ao cartão furtado encontrava-se a respectiva senha, resta patente a negligência do correntista, devendo, pois, assumir os riscos de sua conduta negligente, sendo exclusiva a sua culpa. (TJ-MG - AC: 10000190966770001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data de Publicação: 07/02/2020)

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a ação.

A autora arcará com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizada.

Se interposta apelação contra esta sentença e também eventual recurso adesivo, como nos termos do Código de Processo Civil de 2015, cabe apenas à instância ad quem examinar os requisitos e pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal (art. 1.010, § 3º), providencie a serventia a intimação da parte apelada e/ou da parte recorrente em caráter adesivo pra apresentar, se quiser, as correspondentes contrarrazões, no prazo de quinze dias (art. 1.010, § 1º), sob pena de preclusão e, após, independentemente de nova decisão ou despacho, remeta-se os autos do processo judicial eletrônico (digital) ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Privado, no prazo e com as cautelas de estilo.

Decorrido o prazo de quinze dias contado do trânsito em julgado desta, com ou sem o ingresso em apenso de cumprimento de sentença, archive-se os autos deste processo judicial eletrônico (digital), com as anotações e movimentações constantes do Comunicado CG nº 1.789/2017 da Secretaria de Primeira Instância.

P. R. I.

Bauru, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA